



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0004192-55.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LUCAS DE SOUZA LEANDRO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Tatiana Vieira Guerra**

Vistos.

LUCAS DE SOUZA LEANDRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local, indicado na denúncia, nesta Capital, trazia consigo, para entrega a terceiros, as drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal, além da quantia de R\$ 22,00 em dinheiro.

O réu foi notificado e, desacolhidos os argumentos expostos na defesa preliminar escrita, a denúncia foi recebida, o acusado foi citado pessoalmente e, na audiência de instrução, debate e julgamento, foi decretada a revelia do réu e foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

Em alegações finais, a douta Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, por entender provados os fatos narrados na denúncia, enquanto o ilustre Defensor pediu a absolvição, por insuficiência de prova e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios legais.

É o breve relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

D E C I D O.

A acusação é procedente.

Não é possível a pretendida absolvição, porque as provas, colhidas sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, demonstram a existência material do crime imputado e a autoria atribuída ao acusado, porque preso em flagrante delito com diversas porções de cocaína e maconha, em quantidade e circunstâncias indicativas do comércio e, informalmente confessou o delito.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das porções de droga e laudo do exame químico toxicológico (fls. 108/110), a constatar a propriedade das drogas que, pela quantidade e modo de acondicionamento, além das circunstâncias da prisão, trazem a convicção do comércio ilícito, conforme revelado pela prova oral colhida nos autos.

Na fase policial, confessou que recebeu a quantia de oitenta reais de um indivíduo, para que transportasse as drogas até a rua Tin Tin, fornecendo as suas características, mas, em juízo, não compareceu para confirmar a sua versão.

Porém, seu depoimento feito na fase administrativa foi confirmado em juízo pelos testemunhos dos Policiais Militares responsáveis por sua prisão em flagrante, que não conheciam o acusado e que, em patrulhamento pelo local indicado na denúncia, avistaram o réu caminhando em sentido contrário e, quando foi abordado, em suas vestes, foram encontradas as porções de maconha e cocaína.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Contaram que o réu admitiu que teria recebido a quantia de oitenta reais para levar a droga de um ponto para outro, a pedido de um indivíduo.

Pela quantidade de maconha e de cocaína, bem como pelas circunstâncias da prisão, não é crível supor que essas drogas seriam apenas destinadas ao seu próprio consumo ou mesmo que os policiais ouvidos teriam, sem nenhum motivo, incriminado falsamente o acusado.

Ressalte-se que inexistente idôneo motivo para descrédito aos testemunhos dos Policiais Militares, porque nada nos autos indica tenham alterado a verdade dos fatos em prejuízo do acusado, preso em posse de grande quantidade de cocaína e maconha, apreendidas nos autos, em local conhecido como ponto de venda, sendo que, pela quantidade e variedade, denota-se que os entorpecentes seriam destinados ao consumo de terceiros.

A condição de policiais responsáveis pela segurança pública não é motivo para desqualificação de seus testemunhos que se mostraram coerentes às demais provas e sem qualquer contradição.

Provada a existência material do tráfico de drogas, em todos os elementos do tipo penal, e autoria atribuída ao acusado, inevitável a condenação, passo à dosagem da pena, com observância ao método trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

Na primeira fase de fixação das penas, verifico que a culpabilidade, entendida como reprovabilidade ao agente pela conduta, não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na segunda etapa da dosagem inexistem circunstâncias a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, com fundamento no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena-base em 2/3, já que o réu é primário, sem antecedentes criminais, e nada nos autos indica a dedicação exclusiva às atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Torno final, para o réu a pena de **01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.**

Estabelecida a quantidade da pena, impõe-se a definição da intensidade, com verificação da constitucionalidade da norma do art. 44, da Lei nº 11.343/06, ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, e também a do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado.

Quis a nova Lei de Drogas aperfeiçoar a sanção penal ao operar a distinção entre meros mercadores ocasionais, também merecedores de atenção do Estado, dos comerciantes de droga mais estruturados, verdadeiros empresários do tráfico, ao permitir a redução das penas, em até 2/3, aos primários, de bons antecedentes, que não se dediquem às atividades criminosas, nem integrem organização criminosa.

Distinção há muito reclamada pelos aplicadores do Direito, tem por motivação a menor reprovabilidade da conduta do traficante ocasional e sua pena encontra fundamento e limite com a redução a integrar o tipo penal para os que apresentem as condições subjetivas típicas daqueles que não tenham estruturado envolvimento com o tráfico de drogas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Com a distinção, reconheceu atenuada a culpabilidade – repita-se, entendida não só como fundamento e limite da pena, mas também como reprovação ao agente pelo crime cometido –, resultante do menor desvalor da conduta desviante do traficante ocasional e, com isso, o legislador concretizou o comando inserto na Constituição da República, art. 5º, inc. XLVI, de individualização da pena.

Em obediência a mencionado princípio, o legislador infraconstitucional está vinculado ao direito fundamental do condenado, de que sua pena seja particularizada, não só na qualidade (reclusão ou detenção) ou quantidade da resposta penal, mas também na intensidade, vale dizer, na verificação de necessidade do regime inicial mais gravoso ou se a pena pode ser resgatada sem ingresso no ambiente deletério do cárcere.

Nesse passo, reconhecida a culpabilidade atenuada, porque o legislador da Lei nº 11.343/06 entendeu ser de menor desvalor a conduta do traficante ocasional e concedeu-lhe extraordinária diminuição de até 2/3 das penas cominadas, não é razoável, nem proporcional, impor-lhe o início do cumprimento da pena em regime fechado ou vedar-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Vedação a afrontar os princípios da individualização da pena, por igualar condenados considerados desiguais pela própria lei que os distinguiu, e da proporcionalidade, impeditivo de excesso, a exigir do Poder Judiciário concretizar a resposta penal, com observância às circunstâncias judiciais, dentre elas a culpabilidade – reprovabilidade ao agente pelo desvalor da conduta –, para estabelecimento da pena cominada, quantidade, regime e substituição, tudo conforme disposto nos artigos 59, do Código Penal.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Inevitável o reconhecimento da invalidade da norma proibitiva do início de cumprimento da pena em regime diverso do fechado e da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela violação ao devido processo legislativo, por não observar os comandos constitucionais de individualização da pena, porque, embora tenha cominado para o mesmo crime penas diversas em razão das condições pessoais dos acusados, com reconhecimento do excesso de penas ao primário, exige-lhe igual recolhimento ao cárcere, em regime fechado, a afrontar também o princípio da proporcionalidade.

Não se pretende assumir poderes legislativos, mas, a aproximação do Direito Penal ao Direito Constitucional, implica interpretar as normas penais ao influxo da Constituição da República para verificação da validade daquelas normas que, inevitavelmente, devem conter os direitos fundamentais, além de serem proporcionais e razoáveis às relações humanas, princípios impeditivos de excessos, da pena desnecessária.

Como ensina Luigi Ferrajoli, com a positivação dos direitos fundamentais nas Constituições, a validade das normas infraconstitucionais não é verificada apenas pela observância ao processo legislativo – parlamento competente e procedimento típico –, mas, necessariamente pelo seu conteúdo, que deve albergar os valores positivados na Constituição e, em caso de rompimento, deve ser considerada materialmente inválida e sem efetividade.

Assim é porque: "A sujeição do juiz à lei não é de fato, como no velho paradigma juspositivista, sujeição à letra da lei, qualquer que seja o seu significado, mas sim sujeição à lei somente enquanto válida, ou seja, coerente com a constituição. E a validade já não é, no modelo constitucional-garantista, um dogma ligado à mera existência formal da lei, mas uma sua qualidade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

contingente ligada à coerência – mais ou menos opinável e sempre submetida à valoração do juiz – dos seus significados com a constituição. Daí deriva que a interpretação judicial da lei é também sempre um juízo sobre a própria lei relativamente à qual o juiz tem o dever e a responsabilidade de escolher somente os significados válidos, ou seja, compatíveis com as normas constitucionais substanciais e com os direitos fundamentais por ela estabelecidos." (O Direito como sistema de garantias. In: "O novo em Direito e Política". Org. José Alcebíades de Oliveira Júnior. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1997, p. 100-1).

No mesmo sentido é a advertência de Alberto Silva Franco: "O Juiz e a Constituição devem ter, em verdade, uma relação de intimidade: direta, imediata, completa. Há um nível de cumplicidade que os atrai e enlaça. Na medida em que, de maneira explícita ou implícita, dá-se a positividade constitucional aos direitos fundamentais da pessoa humana, estabelece-se, ao mesmo tempo, um sistema de garantias com o objetivo de preservá-los. O Juiz passa a ser o garantidor desse sistema. Não pode, por isso, em face de violações ou de ameaças de lesão aos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, permanecer num estado de inércia ou indiferença ou mesmo admitir que o legislador infraconstitucional se interponha indevidamente entre ele e a Constituição." ("Crimes Hediondos", 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 71).

Acolhido pela Constituição da República de 1988, ainda que não expressamente nela apontado, mas inferido pela contextualização dos direitos fundamentais nela positivados, o princípio da proporcionalidade constitui adequado instrumento para verificação da razoabilidade de determinada norma legal, da qual é exigível moderação, equilíbrio ao sentido comum, adequação às



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

relações humanas e nunca resultar da vontade arbitrária do legislador, atributos não verificados na enorme diferença de tratamento na vedação de regime inicial menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a recomendar a adequação – pelo Poder Judiciário, guardião dos direitos fundamentais – do meio empregado (pena) ao fim almejado (prevenção e repressão ao crime).

É desproporcional e irrazoável (até irracional) tratar de modo igual, pela mesma intensidade da pena – sempre em regime inicial fechado –, aos que a lei distinguiu com menor quantidade da pena, pois a dosimetria da resposta penal não se cinge apenas à quantidade, mas também ao estágio inicial de resgate, progressão ao mais brando, possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão de sua execução, fixados sempre com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para definição da pena necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, como recomenda o art. 59, do Código Penal, em sua parte final.

Com essa convicção, resultante da interpretação da norma infraconstitucional ao influxo da Constituição da República, consideradas, no caso em tela, as circunstâncias judiciais favoráveis (tanto que a pena base foi fixada no mínimo legal), o **regime inicial será o ABERTO**, que deve ser estabelecido com observância às circunstâncias judiciais, conforme determina o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o regime inicial deve ser adequado à quantidade da pena, que no presente caso permite o estabelecimento do regime aberto, porque o acusado não é delinqüente contumaz, como pode ser inferido nos autos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Neste sentido não se pode olvidar do entendimento sumulado pelo E. Supremo Tribunal Federal de que "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Súmula STF nº 718) e também de que "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula STF nº 719).

Atendidas as condições previstas art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal. Pena privativa de liberdade superior a um ano, aplico, também, 10 dias-multas, cumulada com a pena pecuniária originária.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a acusação e condeno LUCAS DE SOUZA LEANDRO, qualificado nos autos, por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a pena de **01 ano e 08 meses de reclusão**, para início no **regime aberto**, que substituo por prestação de serviço à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 176 dias-multa (166 dias-multa cominado no tipo penal e 10 dias-multa pela substituição), no valor mínimo legal.

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção da para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nos termos do disposto no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, declaro perdido o dinheiro apreendido com o acusado, em favor da União, a ser revertido diretamente ao FUNAD, oficiando-se.

Facultada a interposição de recurso em liberdade, porque primário, inexistente prova de necessidade da prisão provisória e pela pena e substituição aplicadas.

Com o trânsito em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados.

TATIANA VIEIRA GUERRA

Juíza de Direito

São Paulo, 08 de fevereiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**